

1501530-16.2020.8.26.0599

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Ana Claudia Madeira de Oliveira

Comarca: Piracicaba

Foro: Foro de Piracicaba

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 20/05/2022

... e da Juventude por ato infracional análogo ao tráfico de drogas, conforme exposto acima, o réu ostenta outra condenação por tráfico de drogas, com trânsito em julgado após a data dos fatos (fls. 323/324) e, na época em que cometeu o crime em questão, havia sido solto no outro processo de tráfico há pouco tempo.

Tais fatos demonstram habitualidade e progressividade ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Piracicaba

1ª Vara Criminal

Rua Bernardino de Campos, 55, Bairro dos Alemães, Piracicaba - 13419-100 - SP

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Processo nº:

1501530-16.2020.8.26.0599

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial (Flagrante) - 2303122/2020 - 07º D.P. PIRACICABA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DANILO DE SOUZA RODRIGUES

Contr. nº 2020/001366

Aos 19 de maio de 2022, às 13:30 horas, por meio de audiência virtual da 1ª Vara Criminal do Foro de Piracicaba, Comarca de Piracicaba, Estado de São Paulo, sob a presidência do(a) MM. Juiz(a) de Direito Dr(a). Ana Claudia Madeira de Oliveira, comigo assistente judiciária ao final nomeada, o(a) representante do Ministério Público, Dr(a). José Eduardo de Souza Pimentel foi aberta a tele-audiência para instrução, debates e julgamento nos autos da ação supra.

Presente o réu DANILO DE SOUZA RODRIGUES (preso p/outro no CDP Pinheiros III).

Presente a Defensoria Pública na pessoa do Dr. Luiz Antonio Felipe Franchito.

Presente(s) a(s) testemunha(s) comuns: GC JOEL VASCONCELOS DE LIMA e GC PAULO FRANCO JÚNIOR

Antes do início da audiência foi (foram) realizada(s) fotografia(s) do(s) documento(s) de identificação exibidos pela(s) testemunha(s), o que foi aceito pelas partes, (imagem(ns) exibida(s) durante audiência).

Pela M.M Juíza de Direito foi explicado que conforme artigo 8º do provimento CSM nº 2651/22, a audiência será realizada por meio de videoconferência, utilizando-se o aplicativo Teams/Microsoft, conforme disciplina já estabelecida pela Corregedoria Geral da Justiça.

INICIADOS OS TRABALHOS, foi assegurada à defesa oportunidade para entrevista reservada com o(a) acusad(a) e todos os presentes foram retirados da sala, inclusive a M.M. Juíza, seu(sua) assistente e o Promotor de Justiça, de modo a não terem acesso a conversa privada entre o(a) ré(u) e sua defesa.

Pela MM. Juíza foi consignado que: "As testemunhas serão inquiridas cada uma de per si, de modo que não ouçam os depoimentos umas das outras, assim, conduzo os trabalhos, conforme determina o art. 210 do CPP".

Após a identificação pessoal, o(s) depoimento(s) da(s) testemunha(s) arrolada(s)

pela(s) parte(s) (GM Paulo e GM Joel) foram captados e gravados em áudio e vídeo. Pelo Promotor de Justiça foi requerida a palavra manifestando-se nos seguintes termos: MMA. Juíza. Adito a denúncia, apenas para a correção de erro material, para que dela se suprimam todas as menções à "crack", uma vez que as porções apreendidas consistiam em cocaína particulada (e não petrificada).

Após, a Defesa tomou ciência do aditamento declarando que nada tinha a requerer. A seguir, a M.M. Juíza recebeu o aditamento e o réu foi citado, procedendo-se ao interrogatório do acusado.

Pelo(a) MM. Juiz(a) foi declarada encerrada a instrução, determinando que as partes se manifestassem para requerimentos acerca de eventuais diligências.

Em seguida, pelo(a) MM. Juiz(a) foi determinado que as partes se manifestassem em alegações finais.

Pelo(a) Dr(a). Promotor(a) de Justiça foi dito o seguinte: MM. Juiz(a).DANILO DE SOUZA RODRIGUES, qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso no artigo 33 da Lei 11.343/06. De acordo com a denúncia, no dia 4 de dezembro de 2020, por volta das 18 horas e 59 minutos, no cruzamento da avenida Miguel Caparrós com a rua Finlândia, bairro Água Branca, nesta cidade e comarca, DANILO trazia consigo, para fins de tráfico e consumo de terceiros, 12 porções de cocaína, na forma de pedras de "crack", sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar; nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar, o réu tinha em depósito, para fins de tráfico e consumo de terceiros, outras 17 porções de cocaína, na forma de pedras de "crack", sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. O processo teve trâmite regular, cf. fls. 186/187, 190/193 e 202/203. A materialidade foi comprovada pelo boletim de ocorrência de fls. 10/15, auto de exibição e apreensão e fls. 19/20, laudo de constatação de fls. 40/43 e laudo de exame químico-toxicológico (fls. 159/161). A autoria também foi determinada na prova oral coligida. Na Delegacia, o réu negou o tráfico (fls. 7/8). Em Juízo, o acusado afirmou que se encontrava no local adquirindo droga do sujeito que se encontrava no carro. Foi surpreendido com 12 porções de cocaína, mas se destinavam ao próprio uso. Os guardas municipais informaram, em audiência, que, passando pelo local, conhecido ponto de venda de drogas, visualizaram DANILO entregando algo ao condutor de um veículo, em atitude típica do comércio de entorpecentes. Diante da patrulha, DANILO empreendeu fuga, sendo perseguido e contido. Na busca pessoal levada a efeito, constatou-se que o réu trazia consigo 12 pedras de "crack" e R\$ 100,00. No local onde DANILO anteriormente se encontrava quando foi avistado foram encontradas outras 17 pedras de "crack", embaladas de forma idêntica àquelas encontradas com ele. Informalmente, DANILO admitiu que estava vendendo drogas para pagar dívidas. O guarda Paulo, respondendo às perguntas da Defesa, disse que as drogas encontradas na rua estavam próximas à sarjeta. Foi o depoente quem fez a revista ao imputado, após perseguição a pé. O colega Joel foi atrás do réu com a viatura. O guarda Joel falou que o local dos fatos é conhecido por intenso tráfico de entorpecentes. Já houve várias ocorrências da mesma espécie por ali. Finda a instrução, as provas reclamam a condenação. Apesar da negativa do réu, nossas Cortes de Justiça avalizam os depoimentos de policiais, fortes no entendimento de que seria um contrassenso acometê-los da difícil missão de atuar na prevenção e repressão de crimes para, em seguida, negar validade a seus relatos, justamente quando prestam conta em Juízo de seu sensível trabalho (Sobre a validade da palavra dos policiais, cf. TJ-SP - APL: 0000162-52.2013.8.26.0547, Relator: J. Martins, Data de Julgamento: 06/11/2014, 7ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 17/11/2014). Assim, a condenação dos acusados é de rigor. Quanto à pena, DANILO possui maus antecedentes, que derivam da condenação no processo nº 1500827-85.2020.8.26.0599, por tráfico anteriormente praticado. A propósito: Esta Corte Superior de Justiça sedimentou o entendimento de que as condenações relativas a fatos anteriores ao crime em julgamento poderão ser utilizadas para majorar a pena-base, bastando que na data da prolação da sentença já tenha ocorrido o trânsito em julgado da condenação. (STJ - AgRg no AREsp: 243.109-SP, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Publicação: DJe 17/06/2014). Ainda: Condenações por fatos anteriores ao apurado na ação penal de que se cuida, ainda que com trânsito em julgado posterior, não servem para

caracterizar a agravante da reincidência, podendo, contudo, fundamentar a exasperação da pena-base como Maus antecedentes. (HC 87.487/SP, 6.^a T., Min. OG FERNANDES, DJe de 13/08/2012). O antecedente desabonador e a prática anterior de ato infracional equivalente ao tráfico afastam o tráfico-privilegiado e apontam para a necessidade do regime fechado. Pelo exposto, requer-se a procedência da presente ação penal.

Pelo(a) Dr(a). Defensor(a), foi dito o seguinte: MM. Juiz(a). DANILO DE SOUZA RODRIGUES foi denunciado pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, conforme os fatos narrados na inicial acusatória. Recebida a denúncia, o feito teve seu regular trâmite, sendo encerrada a instrução na presente audiência. O Ministério Público requereu a condenação do acusado, nos termos da denúncia. Ocorre, contudo, que a ação penal deve ser julgada improcedente. Excelência, inicialmente é preciso reconhecer que não há provas que permitam concluir, com segurança, que o réu incorreu no crime de tráfico de entorpecentes que lhe foi atribuído. Isso porque a incriminá-lo há apenas a versão dos guardas civis municipais responsáveis por sua prisão em flagrante. Tanto na fase policial quanto em juízo, os agentes municipais relataram que estavam em patrulhamento em área conhecida como ponto de tráfico quando visualizaram o acusado próximo a um veículo branco, passando algo a seu ocupante. Com a aproximação da viatura, o condutor desse veículo deixou o local, mesma providência tomada pelo réu, que saiu em disparada. Contudo, ele acabou tropeçando e caindo, o que permitiu a sua abordagem. Realizada a revista pessoal, encontraram em poder do acusado doze porções de cocaína. Já na sarjeta da calçada, encontraram outras dezessete porções, idênticas a que estavam com o acusado, que então confessou o tráfico de drogas, alegando que devia a traficantes. Já de outro lado, o réu negou a prática delitiva. Ou seja, como se nota, a prova que incrimina o acusado é bem frágil, na medida em que só foram ouvidos os responsáveis pela sua prisão que, evidentemente, são testemunhas parciais. Afinal, não há como negar que os depoimentos dos guardas municipais estão contaminados pela atuação que tiveram na apuração dos fatos, o que gera a necessidade de justificar os atos praticados, até porque é bem questionável se possuem atribuição para atos típicos de polícia repressiva. Assim, ainda que não estejam impedidos de depor, certo é que seus testemunhos devem ser recebidos com cautela, sobretudo no momento de se conferir o devido valor probatório. Não é por outra razão que em diversas ocasiões já se decidiu pela impossibilidade de se fundamentar uma condenação apenas com base na palavra dos responsáveis pela persecução penal: "As palavras dos policiais merecem credibilidade, mas não basta o título (exercício da função de policial). Há necessidade de que estas tenham apoio em evidências circunstanciais e testemunhais, sob pena de exaltar-se um registro indiciário como absoluto, infalível e inquestionável". (TJSP - 7.^a Câ. - Ap. Cr. n. 1.465.651/6 - Com. de Campinas - j. 19/5/2005 - v.u.). No mesmo trilho ensina o professor Gustavo Henrique Badaró (os destaques são nossos): "Quanto aos depoimentos dos policiais, há correntes radicais, que, pelo seu próprio extremismo, devem ser descartadas. Uma dessas correntes entende que o fato de a testemunha ser policial, por si só, não a torna impedida de depor, não havendo qualquer disposição legal neste sentido. Ao contrário, o policial não se enquadra nas hipóteses do art. 207 do CPP, devendo ser dado ao seu depoimento o mesmo valor de qualquer outra testemunha. De outro lado, há corrente oposta, no sentido de que os policiais, pela simples condição funcional, seriam suspeitos. Deve prevalecer uma corrente intermediária: se os policiais não podem ser considerados suspeitos, pelo simples fato de serem policiais, por outro lado, é inegável o seu interesse na demonstração da legalidade de sua atuação nos atos investigatórios praticados, pelo que seus depoimentos têm valor relativo, devendo ser cotejados com outros elementos de provas existentes nos autos, em especial o testemunho de pessoas estranha aos quadros da polícia. Não se pode esquecer que as testemunhas são, por definição, terceiros imparciais, sem qualquer interesse no processo, o que não é exatamente o caso dos policiais em relação aos crimes por eles investigados. Por tais motivos, não se deve admitir que seja proferida uma sentença condenatória com base exclusiva no depoimento de policiais, ainda que estes se mostrem harmônicos entre si". (BADARÓ, Gustavo Henrique. Processo Penal. 8.^a ed. rev. atual. e ampl. São Paulo:

Thomson Reuters Brasil, 2020. p. 588). E, no caso sob análise, para além dos depoimentos dos agentes integrantes aos quadros da segurança pública, nenhuma outra prova foi produzida, pois convenientemente ou não, o condutor do veículo não foi identificado. Assim, verifica-se que as provas produzidas contra o réu são bem precárias, ainda mais considerando o crime que lhe é atribuído, equiparado a hediondo. Não se quer dizer que os agentes municipais mentiram, mas apenas que, para a condenação, prova mais robusta é necessária. A propósito, cumpre registrar que quanto mais se dá crédito a esse tipo de prova, mais se incentiva a precariedade de investigações, o que pode dar azo a abusos e manipulações. Assim, mostrando-se frágil o conjunto probatório, requer-se a absolvição do acusado, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal. De maneira subsidiária, a Defesa pugna pela desclassificação da conduta para a prevista no artigo 28, da Lei de Drogas, uma vez que, ainda que se acolha o que disseram os guardas municipais, verifica-se que com o réu, efetivamente, foram encontradas poucas porções de drogas, além de pequena quantia em dinheiro. A maior parte da droga estava junto a sarjeta, local aberto e acessível a qualquer pessoa. Ora, Excelência, em local conhecido pela venda de drogas não há apenas traficantes, mas também usuários. Além disso, as drogas são compradas com as mesmas embalagens em que são vendidas, não se podendo, a partir disso, concluir-se pela ocorrência do crime mais grave. No caso em tela, há ainda que se desprezar eventual confissão do acusado, pois, se ocorreu, evidentemente se deu ao arrepio das garantias constitucionais, sobretudo aquela que diz respeito à não autoincriminação. Dessa forma, remotamente, só é possível dizer que o acusado incorreu no crime de porte de entorpecente para consumo pessoal, para o qual se requer a desclassificação de sua conduta. No entanto, caso o entendimento de Vossa Excelência seja diverso, em caso de condenação pelo crime de tráfico de entorpecentes requer-se a fixação da pena no mínimo legal, considerando que não houve apreensão significativa de entorpecente. Já na terceira fase é o caso de aplicação da causa redutora de pena do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, pois preenchidos todos os requisitos legais. O réu é tecnicamente primário e não há prova que integre organização ou associação criminosa, até porque houve apreensão de quantidade ínfima de substância entorpecente. Reforça-se que à época dos fatos o acusado era primário, não importando que posteriormente tenha ocorrido a confirmação da condenação do processo que respondia. Assim, não há impeditivo para o reconhecimento do “tráfico privilegiado”, com suas implicações, mormente porque o ato infracional indicado pelo órgão acusatório é bem antigo, referindo-se a ocorrência de julho de 2015. Há, assim, relevante distância temporal entre esse ato infracional e aquilo que é apurado nesses autos (cerca de cinco anos). Assim, presentes os requisitos legais para aplicação da causa minorante, a pena do réu deve ser reduzida em patamar máximo, o que, por consequência, autoriza a fixação do regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, na forma do art. 44, do Código Penal. Por fim, caso não se aplique a causa redutora de pena, requer-se que, ao menos, seja estabelecido o regime semiaberto para o início do cumprimento da pena, bem como seja garantido o direito de recorrer em liberdade, já que ausentes os requisitos da prisão preventiva.

A seguir, pelo(a) MM. Juiz(a) foi proferida a sentença a seguir:

Vistos,

DANILO DE SOUZA RODRIGUES, qualificado nos autos, foi denunciado pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO como incurso no artigo 33, “caput”, da Lei 11.343/06, porque, segundo a denúncia e seu aditamento, no dia 4 de dezembro de 2020, por volta das 18 horas e 59 minutos, no cruzamento da avenida Miguel Caparros com a rua Finlândia, bairro Água Branca, nesta cidade e comarca, trazia consigo, para fins de tráfico e consumo de terceiros, 12 porções de cocaína (cf. foto de fls. 23 e laudo de fls. 40/43), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Consta, também, que, nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar, o réu tinha em depósito, para fins de tráfico e consumo de terceiros, outras 17 porções de cocaína (cf. foto de fls. 23 e laudo de fls. 40/43), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Narra, a denúncia, que os guardas municipais patrulhavam pelo local, conhecido ponto de venda de drogas, quando visualizaram o acusado entregando algo ao condutor de um veículo, em atitude típica do comércio de entorpecentes.

Ao notar a aproximação da patrulha, Danilo empreendeu fuga, mas foi perseguido e contido mais adiante, ao cair ao solo. O acusado foi submetido à busca pessoal pelos guardas municipais, verificando-se, assim, que ele trazia consigo 12 porções de cocaína e R\$ 100,00 obtidos com a venda de entorpecentes.

Narra, ainda, que no local em que Danilo anteriormente se encontrava quando foi avistado pelos GMs, foram encontradas outras 17 porções de cocaína, embaladas de forma idêntica àquelas encontradas consigo, que o acusado tinha em depósito (fls. 23).

Relata a denúncia que foram apreendidas, ao todo, 29 porções de cocaína, com peso bruto aproximado de 33,6g, conforme laudo de constatação de fls. 40/43 e que, informalmente, Danilo admitiu que estava vendendo drogas para saldar dívidas com outros traficantes.

Conclui a denúncia que as circunstâncias da prisão, o fracionamento, a forma do acondicionamento e a confissão informal evidenciaram que as substâncias apreendidas se destinavam ao consumo de terceiros. Ademais, consta que o acusado se dedica ao tráfico desde a menoridade (cf. autos nº 0000691-40.2015.8.26.0567 - fls. 48 e nº 1500827-85.2020.8.26.0599 - fls. 46/47).

O réu foi notificado, por edital, nos termos do artigo 55 da Lei 11.343/06 (fls. 174/175). Não constituiu defensor, nem respondeu aos atos do processo, sendo sua Defesa Preliminar apresentada às fls. 186/187, pela Defensoria Pública. A denúncia foi recebida em 17/06/2021 (fls. 188) e o réu foi citado por edital (fls. 193) e, sem manifestação, o processo foi suspenso nos termos do artigo 366 do CPP (fls. 202/203).

Posteriormente localizado, o réu foi citado pessoalmente (fls. 243) e a decisão que suspendeu o processo e o prazo prescricional foi revogada (fls. 244/245).

Durante a instrução, foram ouvidas duas testemunhas arroladas pelas partes. Ao final, o réu foi interrogado.

Superada a fase de requerimentos de diligências, em alegações finais, o Ministério Público requereu a condenação do réu pelo crime de tráfico de entorpecentes, alegando estarem provadas autoria e materialidade. Pleiteou o afastamento do privilégio.

A Defesa pediu a absolvição, sustentando que as provas dos autos não demonstraram a prática do crime de tráfico de drogas pelo acusado. Subsidiariamente, requereu a aplicação da pena-base no mínimo legal com o reconhecimento do privilégio.

É o relatório.

Decido.

A denúncia procede.

Autoria e materialidade do delito estão comprovadas pelos seguintes elementos:

- 1) boletim de ocorrência de fls. 10/15;
- 2) auto de exibição e apreensão de fls. 19/20;
- 3) fotografias de fls. 23/24;
- 3) laudo de constatação de fls. 40/43 e laudo de exame químico toxicológico de fls. 159/161, ambos com resultado positivo para cocaína em relação às substâncias apreendidas;
- 5) prova oral, que, a seguir, será analisada.

Vejamos:

Na fase informativa (fls. 07/08), o réu negou o crime. Declarou que é usuário de drogas e havia ido buscar entorpecente no local dos fatos. Afirmou que, quando os guardas chegaram, com medo de ser preso, saiu correndo. Porém, caiu no chão e foi detido por eles pelos guardas. Afirmou que portava 9 porções.

Interrogado em juízo (gravação), novamente negou o crime, dizendo que trabalhava nas proximidades e todo dia ia até o local dos fatos comprar drogas. Fez contato com o traficante, que estava de carro, e recebeu dele 12 porções de cocaína. Disse que, quando viu os guardas chegando, saiu correndo. No entanto, foi abordado e com ele os guardas encontraram as 12 porções de cocaína e R\$ 100,00.

A negativa foi afastada pelas provas dos autos.

Com efeito, ouvido na fase extrajudicial (fls. 04/05) e sob o crivo do contraditório (gravação), o guarda municipal Paulo Franco Junior declarou que, na data dos fatos, estava com seu colega em patrulhamento pela cidade e, quando passaram pelo local, já conhecido como ponto de tráfico de drogas, viram o acusado em atitude suspeita na via pública, entregando algo para outro indivíduo que estava dentro de um veículo. Ao avistarem a viatura, o indivíduo do veículo rapidamente deixou o local e o acusado, demonstrando nervosismo, empreendeu fuga, correndo a pé. Desembarcou da viatura e correu atrás do réu, enquanto seu colega o seguiu com a viatura, fazendo um cerco. Quando ele tropeçou e caiu, conseguiu abordá-lo. Na sua posse encontraram, no bolso de sua bermuda, 12 porções de cocaína e o valor de R\$ 100,00, em notas diversas. Voltaram ao local onde o acusado se encontrava inicialmente e, junto à sarjeta, localizaram mais 17 porções de cocaína, embaladas da mesma forma como aquelas que estavam em sua posse. Esclareceu, por fim, que, informalmente, o acusado confessou que estava vendendo as drogas, por R\$ 20,00 cada porção, pois devia para traficantes, alegando, ainda, que correu por medo de ser preso.

No mesmo sentido as declarações prestadas na delegacia de polícia (fls. 06) e na audiência de instrução (gravação), pelo guarda municipal Joel Vasconcelos de Lima. Anoto que os relatos dos guardas civis merecem a normal credibilidade dos testemunhos em geral, eis que inexistem elementos indicando que teriam procedido de má-fé.

Presume-se a lisura dos agentes públicos, pois investidos no cargo para segurança pública. Seria paradoxal o Estado atribuir a tais pessoas a execução de um ato administrativo de polícia preventiva e repressiva, mas não aceitar suas palavras na valoração das provas. Tal raciocínio vem sendo aplicado há muito tempo na jurisprudência geral, com ressonância no Superior Tribunal de Justiça e no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.

Confirmam-se alguns julgados:

"HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. ROUBO COMETIDO COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO, EM CONCURSO DE AGENTES E COM RESTRIÇÃO À LIBERDADE DAS VÍTIMAS. ABSOLVIÇÃO EM 1º GRAU. APELO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDO. CONDENAÇÃO. ALEGADA AFRONTA AO ART. 155 DO CPP. NÃO CONFIGURAÇÃO. PROVA DA AUTORIA COLHIDA EM JUÍZO. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL CORROBORADA PELA PROVA JUDICIALIZADA. VALIDADE PARA FUNDAMENTAR A CONDENAÇÃO. PALAVRA DE POLICIAIS. MEIO DE PROVA IDÔNEO. ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, sedimentou orientação no sentido de não admitir habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício, em homenagem ao princípio da ampla defesa. II - O eg. Tribunal de Justiça, ao modificar a sentença absolutória para condenar o paciente, se fundamentou na prova coligida em Juízo, consistente no depoimento das vítimas e testemunhas, dentre elas policiais que realizaram a prisão em flagrante, os quais corroboraram os elementos constantes do inquérito policial, notadamente a confissão extrajudicial dos agentes, não havendo ofensa ao art. 155 do CPP. III - Esta Corte firmou entendimento no sentido de que a retratação da confissão extrajudicial não é suficiente para elidir sua validade para o convencimento acerca da autoria, quando for corroborada por elementos produzidos sob o crivo do contraditório. IV - O depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes. V - Afastar a condenação, in casu, demandaria o exame aprofundado de todo conjunto probatório, como forma de desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos e provas, providência inviável de ser realizada dentro dos estreitos limites do habeas corpus, que não admite dilação probatória. Habeas corpus não conhecido." (STJ - HC 471.082/SP. QUINTA TURMA. Rel. Ministro FELIX FISCHER - j. 23/10/2018) g.n.

"Tráfico de entorpecentes. Materialidade e autoria comprovadas. Validade das palavras dos policiais. Condição funcional que, por si só, não afasta a credibilidade dos seus relatos. Precedentes. Comércio evidenciado pelas circunstâncias da apreensão. Desnecessidade de prova de atos de mercancia. Conduta típica, ademais, que se perfectibiliza com a realização de qualquer uma das condutas previstas. Condenação acertada. Reincidência afastada. Pena reduzida. Descabimento do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas e de penas alternativas, em razão da dedicação a atividades ilícitas. Condenação por ato infracional equiparado a tráfico de entorpecentes. Regime fechado que deve ser mantido a despeito da quantidade de pena e do tempo de prisão preventiva. Recurso parcialmente provido." (TJSP. Apelação Criminal 1500118-94.2020.8.26.0552. 10ª Câmara de Direito Criminal. Relator (a): DESEMBARGADOR FRANCISCO BRUNO - j. 11/09/2020) - g.n.

No mesmo sentido: 1) TJSP. Apelação Criminal 1505129-40.2019.8.26.0132. 15ª Câmara de Direito Criminal. Relator (a): DESEMBARGADOR WILLIAN CAMPOS - j. 14/09/2020; 2) TJSP. Apelação Criminal 1500964-84.2018.8.26.0228. 9ª Câmara de Direito Criminal. Relator (a): DESEMBARGADOR ALCIDES MALOSSI JUNIOR - j. 14/09/2020; 3) TJSP. Apelação Criminal 1501036-52.2019.8.26.0320. 4ª Câmara de Direito Criminal. Relator (a): DESEMBARGADOR ROBERTO PORTO - j. 14/09/2020; 4) TJSP. Apelação Criminal 0002209-87.2017.8.26.0634. 6ª Câmara de Direito Criminal. Relator (a): DESEMBARGADOR LAURO MENS DE MELLO. j. 12/09/2019; 5) TJSP. Apelação Criminal 1521997-96.2019.8.26.0228. 10ª Câmara de Direito Criminal. Relator (a): DESEMBARGADOR NELSON FONSECA JUNIOR - j. 14/09/2020.

De fato, não se coaduna com a lógica probatória aceitar a alegação do acusado em detrimento da palavra dos guardas: enquanto o interesse destes é apenas relatar ocorrências registradas no cumprimento do dever de ofício, o daquele é eximir-se de sanção penal. Mas não há olvidar a significativa diferença entre ambos: apenas um deles tem o dever-jurídico de dizer a verdade.

Registro que os relatos dos guardas civis não foram infirmados pelas demais provas dos autos.

Diante desse quadro, não há dúvidas de que, no dia e local dos fatos, o réu portava, possuía e tinha em depósito 29 porções de cocaína, as quais eram destinadas ao comércio e consumo de terceiros.

De fato, o réu foi surpreendido em pleno ato de traficância por guardas civis que realizavam diligências pelo local dos fatos, já conhecido como ponto de tráfico de drogas, momento em que efetuava a entrega de algo a um condutor de veículo (isso afasta completamente a inverossímil versão do réu de que estava comprando drogas e que recebeu do traficante, o condutor do veículo, as drogas), em plena via pública. Ao notar que seria abordado, o réu agiu de forma suspeita e absolutamente comprometedor, empreendendo fuga.

Ao ser abordado, em sua posse encontraram parte dos entorpecentes apreendidos e, no local onde ele se encontrava realizando o comércio ilícito, os guardas encontraram o restante da droga descrita na denúncia, a qual, diante das circunstâncias da diligência, não pode ser dissociada do acusado.

Inconteste, dessa forma, que as drogas apreendidas pertenciam ao réu e eram destinadas ao comércio, destino este que se reforça diante da quantidade apreendida (29 porções), incompatível com a situação de mero usuário.

Ainda que se considere a possibilidade de o acusado ser usuário de drogas, a condição de usuário não é inconciliável com a traficância, pois não é incomum usuários traficarem para sustentar o próprio vício e ainda obter algum lucro. Some-se a tudo isso o fato de as drogas estarem embaladas individualmente, em pequenas porções, na forma como comumente são comercializadas (fotografias de fls. 24 e 25).

Outrossim, com o acusado foi encontrada a quantia de R\$ 100,00, em notas trocadas, cuja origem lícita não foi comprovada e, nas circunstâncias da apreensão, certamente era produto das vendas ilegais.

Sobre a viabilidade de esses elementos demonstrarem a destinação comercial dos entorpecentes, cito os seguintes precedentes:

"TÓXICO - TRÁFICO DE DROGAS - Insuficiência de provas - Não configurada. Negativa

de autoria e versão apresentada que restou isolada. Depoimento dos policiais que se mostraram coerentes e firmes. Mensagens que de whatsapp que não se mostraram o principal para configuração do crime. Apenas se somam aos depoimentos dos policiais. Utilizadas para confrontar o réu no momento da abordagem sobre a prática de tráfico de drogas, este admitiu e indicou onde estaria o restante das drogas. Quantidade de droga e acondicionamento que encaminham para o reconhecimento do crime. Desclassificação para o crime de porte de entorpecentes para uso próprio. Não acolhido. Ausência de comprovação de que fosse apenas usuário. De qualquer forma o ser usuário não espanca a condição de tráfico, cada vez mais comum, mesmo porque há necessidade de dinheiro para manutenção do vício, adquirível em outras áreas, ou seja, o usuário vende para terceiros, para conseguir manter o próprio vício. Em regra, a paga é em espécie. Dosimetria da pena. Mantida sem alteração. Regime mantido. Não recomendável mais abrandamento. NEGADO PROVIMENTO AO APELO." (TJSP - Apelação Criminal 0000106-69.2018.8.26.0603 - 3ª Câmara de Direito Criminal - Relator: Ruy Alberto Leme Cavalcheiro - J. 20/07/2020). g.n.

"MATERIALIDADE - Auto de apreensão e laudo toxicológico que restou positivo para a presença do elemento ativo - Comprovação que o material apreendido é droga. AUTORIA - Depoimento de policiais que confirma a abordagem da ré e do menor, cujas características coincidiam com aquelas informadas em denúncia como sendo a dos traficantes, ocasião em que houve apreensão de drogas em poder do menor - Confirmação pelos policiais de que o adolescente afirmou que a ré trabalhava junto na traficância, na função de 'olheira' - Validade - Depoimento policial só deve ser visto com reservas quando a imputação ao réu visa justificar eventual abuso praticado - Inocorrência no caso em tela. TRÁFICO - Destinação a terceiros - Quantidade incomum com a figura do usuário - Forma de acondicionamento das drogas, própria para a venda a varejo - Apreensão de dinheiro - Falta de condições econômicas para a ré possuir a droga para seu uso pessoal - Denúncia - De rigor a condenação da ré - Absolvição - Impossibilidade - Negado provimento ao apelo. CAUSA DE AUMENTO - Prática do delito que envolveu adolescente demonstrada pela prova oral - Causa de aumento do artigo 40, VI, da Lei nº 11.343/06 configurada. PENA - Base fixada em 1/6 acima do mínimo legal - natureza da droga de alto potencial lesivo - Manutenção - Presente a atenuante da menoridade - Redução da pena ao mínimo legal - Súmula 231 do STJ - Presente a causa de aumento relacionada com o envolvimento de adolescente - Exasperação da pena em 1/6 - Reconhecido o redutor na fração de 2/3 - Manutenção ante a inércia ministerial - Dedicção da ré à atividade criminosa - Passagem por ato infracional - Apreensão de considerável quantidade de droga - Profissionalização - Dedicção à atividade criminosa - Manutenção porque vedado a reformatio in pejus - Redução da pena - Impossibilidade - Improvimento ao apelo. REGIME - Fechado - Apreensão de elevada quantidade de droga - Natureza dos entorpecentes que possui alto potencial lesivo - Alta reprovabilidade e periculosidade - Ré que ostenta processo por ato infracional - O regime deve ser o necessário para dissuadi-los a retornar a delinquir (Beccaria) - Regime fechado - Necessidade - Improvimento ao apelo". (TJSP - Apelação Criminal 1502824-11.2019.8.26.0544 - 6ª Câmara de Direito Criminal - Relator: Lauro Mens de Mello - J. 16/07/2020) g.n.

Portanto, pelas condições reveladas, imperiosa a condenação do réu pelo crime do artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06.

Passo à individualização das penas.

Não obstante o réu tenha sofrido condenação em outro processo por tráfico de drogas, a sentença transitou em julgado após esses fatos, de modo que ele deve ser considerado primário e de bons antecedentes.

As demais circunstâncias do artigo 59 do Código Penal não lhe são desfavoráveis. A quantidade de drogas apreendidas, embora significativa a ponto de indicar o tráfico, não fugiu à normalidade da espécie.

Portanto, fixo as penas-base em cinco anos de reclusão e quinhentos dias-multa. Inexistem agravantes.

Eventuais atenuantes, como a confissão informal, não autorizam a redução das penas aquém do mínimo legal.

Inexistem causas de aumento ou diminuição de pena.

Não estão presentes os requisitos do parágrafo 4º, artigo 33 da Lei 11.343/06, uma vez que o réu, embora primário, possui passagem na Vara da Infância e Juventude da Comarca de São Roque, com condenação por ato infracional equiparado ao crime de tráfico de drogas (cópia da sentença condenatória juntada às fls. 111/117 e trânsito em julgado para as partes às fls. 331). Some a isso o fato de, quando foi preso em flagrante pelo crime tratado neste processo, o réu havia acabado de ser condenado em Primeira Instância também por crime de tráfico de drogas, em processo no qual beneficiado com o direito de recorrer em liberdade (fls. 323/324). Ou seja, solto em processo de tráfico de drogas em 11/09/2020 (fls. 323), foi novamente preso em flagrante pelo mesmo crime (agora por este processo), menos de três meses depois, em 04/12/2020, o que não só indica que vem fazendo do tráfico um meio de vida, mas revela ousadia, desprezo pela Justiça e pelas normas do Estado.

Trata-se, portanto, de traficante que vem reiterando nas atividades criminosas, não se podendo equipará-lo aos pequenos e eventuais traficantes.

Registro que a aplicação da minorante exige a existência cumulativa dos quatro requisitos presentes no dispositivo supramencionado, quais sejam: a) agente ser primário; b) possuir bons antecedentes; c) não se dedicar às atividades criminosas; e d) não integrar organização criminosa.

Conforme exposto acima, o réu não preencheu todos esses requisitos, tendo se dedicado às atividades criminosas, notadamente o tráfico de drogas.

No sentido de que, em casos em que o réu ostenta condenação por ato infracional equiparado a tráfico de drogas, é incabível o privilégio, já se manifestou o C. STJ: HC 529.996/SP, Quinta Turma, Rel. Min. RIBEIRO DANTAS, j. 12/11/2019; HC 512.197/SP, Quinta Turma, Rel. Min. JOEL ILAN PACIORNIK, j. 06/08/2019.

No caso dos autos, como se viu acima, além da condenação na infância, o réu ostenta outras circunstâncias que impedem o privilégio.

Quanto ao regime de pena para início de seu cumprimento, não obstante o réu seja primário, entendo que, no caso concreto dos autos, deve ser fixado o fechado, porquanto, além de registrar passagem na Vara da Infância e da Juventude por ato infracional análogo ao tráfico de drogas, conforme exposto acima, o réu ostenta outra condenação por tráfico de drogas, com trânsito em julgado após a data dos fatos (fls. 323/324) e, na época em que cometeu o crime em questão, havia sido solto no outro processo de tráfico há pouco tempo.

Tais fatos demonstram habitualidade e progressividade na conduta, além de destemor, ousadia, maior periculosidade e total desprezo pela Justiça e pelas normas do Estado. Revelam, ainda, que não tem intenção de mudar os rumos de sua vida.

Diante desse quadro e considerando as nefastas consequências do crime de tráfico de drogas, o qual traz graves consequências à sociedade como um todo, fomentando a prática de vários outros delitos, destruindo famílias, vidas e a saúde dos usuários, que não conseguem se livrar do vício, necessária a fixação de regime fechado para início do cumprimento da pena corporal, sem possibilidade de sua substituição por penas restritivas de direitos, estas também incabíveis em razão da quantidade de pena aplicada.

Eleição de regime diverso e aplicação de penas substitutivas da corporal, no caso concreto dos autos, impediriam que a pena cumprisse suas funções de prevenção e reprovação dos crimes, pois não fariam com que o réu sentisse as consequências de seu grave ato e, considerando que já vem traficando há algum tempo, desde que era menor de idade e que não demonstrou arrependimento, muito provavelmente continuaria a realizar o nefasto comércio.

Cada dia-multa terá o valor mínimo legal, diante da ausência de elementos para se verificar as condições econômicas do réu.

Diante do exposto e de tudo o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a denúncia e CONDENO o réu DANILO DE SOUZA RODRIGUES a cumprir cinco anos de reclusão, inicialmente em regime fechado, e a pagar quinhentos dias-multa, no valor unitário mínimo legal, por ter infringido o artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06. Ausentes os requisitos da prisão preventiva, concedo ao réu o direito de recorrer em liberdade.

Custas na forma da Lei 11.608/03.

Publicada em audiência, registre-se, intime-se, comunique-se, expedindo-se o mais

necessário.

Pelo RÉU, DEFESA e MINISTÉRIO PÚBLICO foi dito que se manifestariam sobre sentença ora proferida no prazo legal.

Pela MM. Juíza de Direito, a seguir, foi dito:

Saem as partes cientes da sentença proferida e do prazo para oferecimento de eventuais recursos.

Todas as ocorrências, manifestações, declarações e depoimentos foram captados e gravados por esse sistema virtual, sendo a mídia disponibilizada posteriormente no sistema SAJ/PG

Para constar, lavrei este que lido e achado conforme, vai devidamente assinado digitalmente pelo(a) MM^(a). Juiz(a). Certifico as presenças dos mencionados na presente ata e deixo de cumprir o disposto no artigo 145, III das NSCGJ. O referido é verdade e dou fé. Saem os presentes devidamente intimados. NADA MAIS. Eu, Tatiana Carlucci Magalhães, assistente judiciário, digitei.